

1500144-64.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO FERNANDES LIMA

Comarca: Porangaba

Foro: Foro de Porangaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/12/2022

... de praticar, reiteradamente ou não, tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo a denúncia, os réus GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA CONSOLMAGNO, OLIVER DOMIGUES ALVES e LAIZA VIEIRA DE MORAIS se associaram para a prática do tráfico de entorpecentes no Município de Guareí. Com esse propósito, ajustaram que GUILHERME seria o responsável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porangaba

Foro de Porangaba

Vara Única

RUA VEREADOR BRAZ GICA DA PAZ 193, Porangaba-SP - cep 18260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500144-64.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500144-64.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026218/2022 - DEL.SEC.ITAPETININGA, 2026218 - DEL.POL.GUAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OLIVER DOMINGUES ALVES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO FERNANDES LIMA

Vistos.

GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA CONSOLMAGNO, OLIVER DOMIGUES ALVES e LAIZA VIEIRA DE MORAIS, todos qualificados nos autos, foram denunciados por infração aos artigos 33, caput e 35 da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 18h30, na estrada vicinal José Francisco de Meira, na cidade de Guareí; comarca de Porangaba, transportavam, 07 (sete) pedras e 01 (uma) porção grande de "crack", com peso bruto de 202,88 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, no mesmo dia, no bairro Morada do Sol, na cidade de Guareí, comarca de Porangaba, ADRIAN DIUARE SANTOS e LAIZA VIEIRA DE MORAIS, guardavam, para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, com peso bruto de 16,58 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA CONSOLMAGNO, OLIVER DOMIGUES ALVES e LAIZA VIEIRA DE MORAIS, em data anterior ao dia 28 de fevereiro de 2020 até a presente data, na cidade de Guareí, associaram-se de forma estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo a denúncia, os réus GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA CONSOLMAGNO, OLIVER DOMIGUES ALVES e LAIZA VIEIRA DE MORAIS se associaram para a prática do tráfico de entorpecentes no Município de Guareí. Com esse propósito, ajustaram que GUILHERME seria o responsável pela aquisição das drogas e distribuição entre os demais, que eram responsáveis pela venda aos usuários.

Tomando conhecimento destes fatos, bem como que, no dia dos fatos, GUILHERME, ADRIAN e OLIVER iriam para a cidade de Angatuba comprar drogas para revender em Guareí, policiais militares realizaram diligência e localizaram os três denunciados em um veículo vermelho, retornando do município.

Em abordagem, localizaram no interior do veículo as porções de crack apreendidas. Apurou-se então que GUILHERME entrou em contato com o vendedor da substância ilícita em Angatuba, ajustando a sua aquisição, tendo então chamado ADRIAN e OLIVER, que o acompanharam aquele município para buscar a droga.

A droga adquirida seria fracionada e dividida pelos denunciados, para posterior venda.

Após a apreensão das porções de crack, os policiais se dirigiram à residência do denunciado ADRIAN, na qual também morava a denunciada LAIZA, sua companheira. Ao chegarem ao local e chamarem pela denunciada, esta correu para dentro do imóvel e jogou a droga que guardavam na privada, dando descarga.

Entretanto, os agentes conseguiram localizar a droga no esgoto nos fundos da casa, apreendendo as porções de cocaína, que os indiciados ADRIAN e LAIZA guardava para venda aos usuários.

Argumenta o Ministério Público que os réus constituíam associação criminosa, tendo em vista que eles transportavam e guardavam consigo drogas destinadas ao comércio mediante ajuste prévio.

Notificados, os réus apresentaram defesa preliminar, na forma do artigo 55 da Lei n.º 11.343/06 (folhas 454 a 455, 463 a 468, 484 e 499 a 500).

Denúncia recebida em 19 de setembro de 2022 (folhas 513 a 514).

Os réus foram citados e instruindo a ação penal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Os réus foram interrogados (folhas 539 a 540).

Determinado o desmembramento dos autos em relação a LAIZA VIEIRA DE MORAIS (folhas 539 a 540)

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão

punitiva, por entender provadas as acusações de tráfico de entorpecentes e associação (folhas 560 a 563).

A Defesa ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA, arguiu em preliminar a nulidade das provas obtidas em violação à inviolabilidade da busca pessoal. No mérito, postula a absolvição, aduzindo, em síntese, que não concorreu para os crimes descritos na denúncia, alega que desconhecia a intenção de Guilherme de buscar drogas, acreditava que estavam apenas indo até Angatuba. Aduz que Guilherme reconheceu a propriedade do entorpecente. Alega que não são suficientes as provas para condenação, defende que não está caracterizado o vínculo associativo estável e permanente, que configura a associação, defende que as provas produzidas são inconsistentes e, portanto, insuficientes para a condenação; pretende a improcedência da pretensão punitiva, subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento do tráfico privilegiado (folhas 567 a 583).

A Defesa de OLIVER DOMIGUES ALVES, arguiu em preliminar a nulidade das provas obtidas em violação à inviolabilidade da busca pessoal. No mérito, postula a absolvição, aduzindo, em síntese, que não concorreu para os crimes descritos na denúncia, alega que desconhecia a intenção de Guilherme de buscar drogas, acreditava que estavam apenas indo até Angatuba. Aduz que Guilherme reconheceu a propriedade do entorpecente. Alega que não são suficientes as provas para condenação, defende que não está caracterizado o vínculo associativo estável e permanente, que configura a associação, defende que as provas produzidas são inconsistentes e, portanto, insuficientes para a condenação; pretende a improcedência da pretensão punitiva, subsidiariamente, em caso de condenação, o reconhecimento do tráfico privilegiado (folhas 584 a 600).

A Defesa de GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, arguiu em preliminar a ilicitude das provas produzidas durante a abordagem policial postula a absolvição, aduzindo, em síntese que as provas produzidas são insuficientes para a condenação, aduz que as provas produzidas não deixam clara a associação para o tráfico, não evidenciando o vínculo estável e permanente; pretende a improcedência da pretensão punitiva, subsidiariamente, em caso de condenação, pede o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea (folhas 601 a 615).

A seguir os autos vieram conclusos.

Este é, em síntese, o relato do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que visa à apuração do cometimento dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Os réus suscitaram em preliminar a ilicitude da prova produzida a partir de informação anônima que levou à busca pessoal, realizada sem que houvesse fundadas suspeitas, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada nulidade de busca pessoal, reputo inconsistente a alegação.

Inicialmente porque, ao contrário da busca domiciliar, que exige a presença de fundadas razões para que seja autorizada pelo juiz, a busca pessoal pode ser realizadas apenas com base em fundadas suspeitas, cuja motivação decorre de juízo subjetivo da autoridade que a executa.

Acrescento que os policiais relataram que receberam informações proveniente de fonte não identificada, que lhes permitiram dar início a uma campanha, que tinha por

objetivo a abordagem do veículo vermelho indicado na informação.

A existência de fonte independente, sem qualquer relação com a busca pessoal, cuja legalidade se questiona, por si só afasta a alegada prova ilícita por derivação, já que as atividades ilícitas dos réus já eram de conhecimento dos policiais militares, tanto que a busca pessoal, desencadeada pelas fundadas suspeitas, só vieram confirmar a veracidade das informações anônimas.

Quanto à alegada nulidade da investigação fundada em informação anônima, assinalo que tal tese não pode ser admitida. Basicamente porque a comunicação de um fato criminoso para a autoridade policial não impõe como condição, para a apuração do fato ilícito relatado, a identificação do informante, trata-se, na hipótese, da denominada notitia criminis inqualificada, Admitido o início de investigação por notitia criminis anônima, vide julgamento do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Min. Celso de Mello, no MS 24.369/DF, 10.10.2002, DJ 16.10.2002, p 24.

No mesmo sentido a doutrina de Maurício Henrique Guimarães Pereira, citado por Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 6ª ed., RT, 2007, p. 77: "O nosso particular entendimento é de que, em sede de comunicação anônima, a própria lei concilia os interesses da administração da justiça e da honra objetiva do denunciado, que são, os bens jurídicos tutelados no crime de denunciação caluniosa, com o princípio da obrigatoriedade, que é comum a ambas as fases da persecução penal, ao dispor que 'qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação penal pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial', mas, esta, somente após verificar 'a procedência das informações', por força da vedação constitucional, mandará instaurar inquérito (art. 5.º, § 3.º [CPP])".

Oportuna, no mesmo sentido, a menção à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a admissibilidade, de dar-se início a uma investigação criminal com base em notitia criminis inqualificada: "TRÁFICO - Caracterização - Denúncia anônima da prática do comércio ilícito - Policial que disfarçado de comprador adquiriu cocaína da filha da ré - Apelante que tinha em depósito 160,22g de maconha - Suficiência probatória - Inadmissibilidade de desclassificação para a figura do artigo 16 da Lei nº 6.368/76 - Ausência de prova de ser a droga para exclusivo uso próprio - Recurso não provido". (TJSP - Ap. Crim. nº 239.368-3 - Pindamonhangaba - 3ª Câmara Criminal - Rel. Walter Guilherme - J. 14.04.98 - v.u); ou ainda: "TRÁFICO - Caracterização - Réu que entregou ao comparsa, que tinha em depósito, 2.100 Kg de maconha - Testigos policiais harmônicos - Inexistência de parcialidade ou interesse particular dos investigadores - Admissibilidade de notitia criminis veiculada por meio de denúncia anônima - Caracterização do artigo 18, III, da Lei nº 6.368/76 - Concurso de agentes que não exige associação de caráter duradouro - Irrelevante não terem os agentes praticado a mesma conduta do tipo, até porque é usual que exista divisão de tarefas - Recursos dos réus improvidos, provido o do Ministério Público". (TJSP - Ap. Crim. nº 253.036-3 - São José do Rio Preto - 3ª Câmara Criminal - Rel. Walter Guilherme - J. 15.12.98 - v.u).

Desta forma, nada há de ilícito nas provas produzidas, pois a informação anônima serviu de base para que os policiais militares, com fundadas suspeitas, abordassem o veículo vermelho proveniente de Angatuba e, após realizarem a busca pessoal, confirmaram o transporte dos entorpecentes pelos denunciados.

No mérito, a pretensão punitiva procede.

A materialidade do crime está em evidência no boletim de ocorrência (folhas 17 a 20), auto de exibição e apreensão (folhas 21 a 22) e no exame químico toxicológico (folhas 551 a 553).

Quanto à autoria, ao serem interrogados pela Autoridade Policial, Guilherme admitiu ter ido até Angatuba buscar entorpecentes que depois de vendido deveria pagar R\$ 5.800,00 para shampoo. Pretendia revender essa droga para Rodrigo de Cesário Lange por R\$ 7.800,00. Disse haver convidado Oliver e Adrian mas não informou a eles o verdadeiro motivo da viagem a Angatuba, disse que iria levar um dinheiro e fumar um baseado (folhas 06 a 07). Adrian admitiu que durante a viagem para Angatuba Guilherme disse que buscaria 200 gramas de crack e pediu ajuda para picar o crack. Disse não ter falado nada sobre aceitar ou não a proposta de Guilherme. Guilherme pegou a droga para picar em Guareí e vender. No trajeto, estavam fumando um baseado e foram abordados pela Polícia Militar, que encontrou drogas no veículo. De lá, foram até a residência de Adrian onde havia pinos de cocaína destinados à venda (folhas 08 a 09). Oliver disse ter acompanhado Guilherme e Adrian a Angatuba. Em Angatuba ficaram em um bar aguardando o retorno de Guilherme e retornaram para Guareí. Foram encontradas drogas no veículo (folha 10).

Quando interrogado em audiência judicial, Oliver disse que não foi questionado pelos policiais, disse que estava na praça com Adrian quando apareceu Guilherme e foram com ele até Angatuba. Guilherme deixou Adrian e Oliver em um bar. Guilherme recebeu uma ligação e saiu. Ficou um tempo fora e voltou. No retorno para Guareí foram abordados pela Força Tática. Os policiais algemaram e colocaram na viatura. Não viu mais nada. Foram então para casa de Adrian, não sabe se foi encontrado algo na casa de Adrian. Não sabia da existência de drogas no carro.

Quando interrogado em audiência, Adrian disse que não é traficante. Já foi internado na Fundação Casa por tráfico de drogas. Foi para Angatuba com Guilherme. Encontrou Oliver na praça e foram com Guilherme até Angatuba para levar produtos de lavador. Em Angatuba, ficaram em um bar e Guilherme recebeu uma ligação e saiu. Ele retornou e foram abordados por policiais militares. Revistaram o carro e encontraram drogas. Os policiais o levaram até sua casa e confirmou ter indicado aos policiais onde havia drogas na residência. Confessou na fase policial porque foi pressionado.

O acusado Guilherme, em interrogatório, disse que tinha um lavador. Recebeu uma proposta e como estava precisando de dinheiro, aceitou transportar drogas até Cesário Lange. No dia dos fatos pegou o carro do pai e convidou Adrian e Oliver, que o acompanharam até Angatuba. Na cidade deixou Adrian e Oliver em um bar, recebeu uma ligação e foi buscar a droga. No retorno foram abordados pela Polícia Militar. Adrian foi pressionado. Foram até Guareí e pararam em frente à casa de Laiza, que acabou presa. Está arrependido.

Durante o contraditório constitucional um dos policiais disse que estavam em patrulhamento na data no município de Guareí, quando próximos da área central foram solicitados por um homem que relatou ter ouvido uma conversa entre Guilherme, Adrian e Oliver, em que estes combinavam uma viagem até Angatuba para buscar drogas em um veículo vermelho Gol pertencente ao pai de Guilherme, foram relatados os nomes e as características deles. Cientes dessa informação foram até o local mais provável de retorno de Angatuba, ficaram aguardando por 30 minutos no local. Quando avistaram um veículo vermelho com as características passadas, fizeram a abordagem. Dentro do veículo havia três pessoas, Guilherme, Adrian no banco do passageiro e no banco de trás, Oliver. Nada foi localizado com os ocupantes do veículo. Fizeram então busca no veículo, onde encontraram no banco da frente, onde estava sentado Adrian, localizaram o "crack" e no banco de trás um saco contendo mil pinos vazios. Indagados separadamente, Guilherme confirmou que havia comprado a droga em Angatuba e por ela havia pago vinte e nove reais o grama e que essa droga seria revendida em Guareí. Adrian e Oliver disseram que trabalhavam para Guilherme revendendo as drogas em Guareí. Adrian confessou que havia mais drogas em sua residência. Foram até a residência, um sobrado e no local, a esposa de Adrian, Laiza, ao perceber a chegada dos policiais, retornou para o interior da casa. A mãe de Laiza saiu para atender os policiais e autorizou a entrada dos policiais. Informaram a Laiza que

Adrian havia confessado a existência de drogas na casa, Laiza negou, posteriormente admitiu e disse que havia jogado no vaso e dado descarga. A rede de esgoto era aberta e saía nos fundos da residência. Os policiais então foram até os fundos e localizaram um saco plástico contendo vinte e quatro pinos de cocaína.

O outro policial militar em depoimento judicial, disse que ratificou a versão do colega, dizendo que receberam informações de que três indivíduos em um veículo Gol vermelho teriam ido até Angatuba buscar drogas. Diante dessas informações, fizeram patrulhamento nas possíveis rotas de retorno de Guareí, após um tempo, visualizaram um veículo Gol vermelho e fizeram abordagem dos três indivíduos que estavam no veículo. Localizaram drogas e microtubos vazios no interior do veículo. Em conversa com os indivíduos separadamente, os três assumiram a destinação da droga para venda e Adrian informou a existência de trinta pinos em sua residência. Na residência Laiza teria descartado as drogas no vaso sanitário, mas como se tratava de fossa, com saída nos fundos da casa, em vistoria, os policiais localizaram 24 microtubos de cocaína.

As testemunhas arroladas pela defesa, inquiridas em audiência, não presenciaram os fatos mencionados na denúncia se limitaram a discorrer sobre a conduta social de Laiza.

A versão dos réus não convence, primeiro porque havia informações anônimas dando conta de que eles teriam combinado previamente a viagem até Angatuba para buscar as drogas que seriam revendidas, fato confessado por Adrian em interrogatório na fase policial e confirmado pelos policiais militares ouvidos em audiência, versão que se revelou verossímil com a abordagem do veículo e apreensão no interior do veículo de várias porções de drogas e microtubos vazios destinados ao acondicionamento desses entorpecentes..

Quanto à versão dos réus de que não sabiam o motivo da viagem de Guilherme, entendo que dar crédito a essa versão, na forma contada pelos réus, além de inverossímil, seria ignorar os indícios existentes nos autos e cair em flagrante ingenuidade.

Em primeiro lugar cabe ponderar que já havia informação anônima repassada ao policial militar indicando a intenção dos três acusados, devidamente identificados, que a bordo de um veículo Gol vermelho, iriam até Angatuba buscar entorpecentes para revenda. As informações foram confirmadas e resultaram na prisão dos réus, retornando de Angatuba com os entorpecentes que haviam buscado naquela cidade. Os policiais, em princípio, não tinham motivos para incriminar falsamente os réus, o que evidencia que os réus, pelas circunstâncias da prisão, atuavam juntos na busca dos entorpecentes e revenda, tanto que se associaram para prosseguir no tráfico, o que ficou provado com a apreensão de entorpecentes no veículo e na residência de Adrian. Assim, não restam dúvidas de que ADRIAN, OLIVER e GUILHERME, associados para o tráfico foram juntos até Angatuba e retornaram juntos com a droga que seria fracionada, acondicionada nos microtubos apreendidos e revendida aos usuários.

Aliado a tudo isso, estamos diante de pessoas com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e procedimentos na Vara de Infância e Juventude por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, como admitido por eles em interrogatório.

Dispõe o artigo 28, § 2º da Lei Federal nº 11.343/06: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". E, no caso destes autos, há indícios suficientes para a classificação do delito como tráfico ilícito de entorpecentes.

Como já afirmado, o crime atribuído aos denunciados é de natureza permanente (transportar e guardar, com fins de venda – todos os verbos têm o mesmo conteúdo

físico que é o reter, a detenção). E, o crime já estava consumado antes da abordagem realizada pelos Policiais Militares. Para a caracterização do delito do artigo 33 da Lei Federal n.º 11.343/06, na modalidade de traficância, não se exige a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da ação policial e das prisões evidenciem a atividade delituosa. Neste caso, foi demonstrado que os réus, previamente ajustados, foram juntos até Angatuba, efetivamente adquiriram drogas na cidade de Angatuba e traziam consigo essas drogas para futura revenda ou distribuição na cidade de Guareí.

A quantidade de substâncias apreendidas 07 (sete) pedras e 01 (uma) porção grande de "crack", com peso bruto de 202,88 gramas e 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, com peso bruto de 16,58 gramas, a forma de embalagem da "cocaína" apreendida, conjugados às informações anônimas e a apreensão, em poder dos réus, de além de pinos apropriados para acondicionamento, corroborados pelos depoimentos prestados durante a instrução criminal, no qual as versões são coincidentes, sobretudo quanto ao local de apreensão, características do veículo e identificação dos réus como adquirentes da droga e ocupantes do veículo no qual a droga seria encontrada em caso de abordagem, pontos que guardam exata correspondência com as informações anônimas recebidas pela Polícia Militar, são mais do que indícios de que os réus se associaram e se dedicavam à distribuição e comércio de substâncias entorpecentes.

O crime autônomo, de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei n.º 6.368/76, também restou seguramente demonstrado, uma vez que os policiais militares, quando ouvidos em juízo, disseram que réus Adrian e Oliver eram indicados como traficantes associados a Guilherme, para quem trabalhavam e por essa razão os Policiais Militares já esperavam os réus na estrada para abordagem. As informações de que os réus estavam juntos no momento da apreensão e tinham ido juntos para Angatuba buscar as drogas que foram apreendidas com eles, reforçam a convicção deste juízo de que os réus se dedicavam e eram, em conjunto, os responsáveis pela distribuição do entorpecente; ademais, Essa associação, na forma retratada pelos policiais militares, que confirmaram que a informação anônima versava sobre o concurso dos três réus na aquisição e transporte de drogas até Guareí.

O artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, exige, para a caracterização da associação criminosa para fins de tráfico, a junção de duas ou mais pessoas, sendo a existência de apenas duas pessoas associadas para a prática do tráfico, suficiente para inseri-los no tipo penal específico do mencionado artigo 35 da Lei Antitóxicos.

Também não há dúvidas de que as condutas dos réus devem ser equiparadas aos crimes hediondos. O fato de participar ativamente na distribuição dos entorpecentes, mesmo que para terceira pessoa não identificada, é conduta típica prevista no artigo 2º, caput, da Lei Federal n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, que equipara o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ao crime hediondo, para fins de estabelecer restrições de benefícios à liberdade (no curso da ação penal e no da execução), reduzindo-os ou vedando-os. E, quando o legislador fez referência ao "tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins" é óbvio que abrangeu todas as modalidades do caput do artigo 33 da Lei Federal n.º 11.343/06, inclusive o ter em depósito a droga para fins de venda, oferecer ou fornecer ainda que gratuitamente.

Sempre oportuno lembrar que traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como por exemplo, aquele que as tem em depósito" (RF 320/237). Há de se ponderar que, as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado

tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO).

É imperioso tecer algumas considerações sobre o nefasto comércio ilegal de drogas, o que vem contaminando de forma irremediável nossos jovens, nossa sociedade, nosso País: "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores da cidade. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

Se o aparelho Judiciário não se comover com tão pungente crescimento do tráfico ilícito de drogas, e não souber dar resposta punitiva adequada, será bem apropriado acoimá-lo de insensível, pusilânime e inútil. Cesare Beccaria, conhecido como o "Marquês de Beccaria", já havia antecipado que é a celeridade e a presteza da pena, mais que a sua severidade, que produz a efetiva intimidação ("Dos Delitos e das Penas", págs. 71/72, ed. RT, 1996).

Copiando, literalmente, as considerações do eminente Juiz CORRÊA DE MORAES, do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, relator do venerando acórdão nos autos da Apelação nº 1.053.139/7, da Comarca de São José do Rio Preto, apreciando a conduta do agente acusado da prática do crime de roubo, este Juiz utiliza-se das mesmas palavras para se referir aos agentes que traficam ilicitamente drogas: Escandaliza e revolta ver como falsos humanistas – espicaçados por patológicos sentimentos de culpa ou acoroados por farisaica e piegas comisseração por facínoras – se alvoroçam e se mobilizam, sempre que, diante da crescente ousadia e expansiva analgesia moral dos traficantes, surgem propostas de reforço da eficácia intimidativa e dissuasória da pena. Obrando com a mais disfarçada improbidade intelectual, os falsos humanistas põem nos defensores de Justiça Penal austera tacha de reacionários, retrógrados, porque, em sua óptica desonesta, estariam em oposição às "tendências do direito penal moderno". Ora isso é cavilação, bluff. O que esses indivíduos refratários aos sofrimentos da população ordeira consideram "tendências do direito penal moderno" não passa de cerebrinas lucubrações de uns poucos nefelibatas, cientistas de gabinete, prisioneiros de delírios quiméricos. Na verdade, o ordenamento repressivo no chamado "primeiro mundo" é tendencialmente sempre mais rigoroso. Humanismo sadio é o que se volta para o trabalhador pacato; para a faxineira e para a lavadeira (que não delinquem); para o balconista e para o ascensorista (que não delinquem); para o metroviário e para o bancário (que não delinquem); para o rurícola, cujo único "crime" é suplicar um pedaço de terra; para o funileiro, o carpinteiro, o operário em construção (que não delinquem); para todos quantos se vêem submetidos a formas espoliativas de trabalho, abrigam-se em sub-habitações, alimentam-se precariamente, vestem-se mal, afligem-se em corredores de hospitais deficientes (e não delinquem, não delinquem, não delinquem, porque mansos de espírito, puros, dotados de boa índole). Falso e hipócrita "humanismo" é o que prodigaliza benesses aos que traficam, estupram, seqüestram, roubam e matam. Suposto que houvesse inexorável nexos de causalidade entre miséria e delinquência, todos os pobres e desvalidos seriam, mais dias, menos dia, tangidos para o crime, porque, presentes as mesmas condições, era de se esperar que se produzissem análogos efeitos. Contudo, não é assim que se passam as coisas. Milhões de brasileiros vêm da miséria ou ainda nela vivem e, sem embargo, não delinquem. Repugna ao bom senso que o juiz se recuse a punir adequadamente o

criminoso, por “condescendência filosófica”. Não está o juiz no mundo para condenar sempre – impulsionado por sanha primitiva. Tampouco para absolver sistematicamente – movido por uma espécie de irreprimível volúpia piedosa. Está para julgar serena e despreconceituosamente, acolhendo a pretensão punitiva e aplicando reprimenda necessária e suficiente para “reprovação e prevenção do crime” (Código Penal, art. 59), quando as provas indicarem essa solução (ainda que isso lhe cause, e necessariamente causará, desconforto emocional), e adotando a fórmula inversa, quando não se constatarem no processo evidências razoáveis. Não é lícito ao juiz fazer da leitura das provas um exercício de transformação alquímica, nelas descobrindo o que elas não traduzem. Não lhe é consentido substituir a verdade do processo pelas “verdades” integrantes de sua concepção do universo e da existência. Não pode e não deve, sob o domínio de opressivas exigências confessionais, entregar-se à tolerância excessiva para com o criminoso. A tolerância, como tudo o mais, deixa de ser virtude positiva, no momento mesmo em que se converte em cornucópia de benefícios indevidos. Não se relegue ao óbvio esta verdade histórica: todos os sistemas cosmogônicos, teológicos e (mais destacadamente) escatológicos – sem excetuar os que têm na tolerância um de seus mais sagrados postulados, como o cristianismo – trabalham com a idéia de que os transgressores impenitentes serão danados e para a eternidade! Ora, se as religiões anunciam o fogo eterno, porque o juiz, pretextando fidelidade devocional, há de acenar tolerantemente com o criminoso com a antecipação da bem-aventurança? Em síntese: Justiça Penal perdida do desvio do fatalismo socioeconômico, complacente, timorata, incapaz de distinguir entre a crueldade do bandido e o sofrimento da vítima, hesitante no momento de segregar o facínora, não é justiça viva, mas demissionária, abdicante, morta”.

Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, Atendendo ao método trifásico de individualização da sanção criminal prevista nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, com vistas à aplicação da pena justa e necessária à reprovação e prevenção do crime, Passo à dosimetria da pena:

Atento às circunstâncias dos artigos 59, caput, e 60, ambos do Código Penal, e considerando-se que, para a aferição das circunstâncias legais para a fixação das penas, em se tratando de tráfico de entorpecente, tem poder decisivo a quantidade da droga apreendida, ficando evidenciada a extrema gravidade da conduta delituosa e, conseqüentemente, a periculosidade dos agentes, hipóteses em que as maiores reprovabilidades social e jurídica se expressam através do agravamento das penas, estabelecidas segundo seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (artigo 59 do Código Penal). Considerando-se que, esse tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (JSTJ, Lex, vol. 127/323-328, rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA) e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n.º 325.444.3/7, rel. Desembargador OLIVEIRA PASSOS), não se podendo tratar da mesma forma o traficante que se dedica à venda de alguns cigarros de maconha, àquele que se presta à comercialização de uma diversidade de entorpecentes, no caso 07 (sete) pedras e 01 (uma) porção grande de “crack” e 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, circunstância que permite aferir terem os denunciados, colaborado dolosamente para a difusão da substância entorpecente.

A lei prevê pena mínima de 05 anos e 500 dias-multa e máximo de 15 anos e 1500 dias-multa.

O artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Com relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, atendendo à culpabilidade dos GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA CONSOLMAGNO, OLIVER DOMIGUES ALVES, às circunstâncias da infração e à quantidade de drogas apreendidas, fixo a pena privativa de liberdade no mínimo legal, perfazendo

um total de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, para os réus GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA CONSOLMAGNO, OLIVER DOMIGUES ALVES, deverá ser utilizado o mesmo critério para a aplicação da pena por violação do artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, fixando-se para cada um dos réus a pena de 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Os réus são primários, de modo que, não se verificam circunstâncias agravantes a aptas a majorar-lhes a pena privativa de liberdade.

No que concerne ao pedido da Defesa para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao réu Guilherme, a tese defensiva não merece acolhida. A confissão extrajudicial só funciona como atenuante se não infirmada em juízo. Portanto, negada a autoria ou alterada a versão dos fatos no interrogatório judicial, fica afastada a atenuante.

Nunca é demais afirmar que em seu interrogatório judicial, o réu apresentou confissão parcial, na qual se limitou a descrever a conduta criminosa e a todo tempo, tentou isentar os demais de responsabilidade, a fim de descaracterizar o crime autônomo de associação para o tráfico, apenas reafirmou ter agido por necessidade financeira. Assim, não vejo como admitir, no caso em comento, a atenuante da confissão espontânea. A doutrina é uniforme em afirmar que não basta a simples confissão para que se configure a atenuante; "exige a lei que ela seja espontânea, de iniciativa do autor do crime e que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico demonstrando arrependimento" (MIRABETE).

Acrescento que o reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, mesmo que aplicável ao caso, não propiciaria a redução da pena privativa de liberdade aplicada porque a pena se manteve no mínimo legal cominado abstratamente nas duas infrações penais, inviabilizando a redução pelo reconhecimento de circunstância atenuante, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verificam outras causas de aumento ou de diminuição de pena passíveis de serem consideradas.

Reconheço o concurso material de crimes para somar as penas e fixar a pena privativa de liberdade para GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA CONSOLMAGNO, OLIVER DOMIGUES ALVES em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa; que torno definitiva.

Os réus GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA CONSOLMAGNO, OLIVER DOMIGUES ALVES agiam associados e constituíram organização criminosa para dar continuidade à disseminação de entorpecentes na cidade de Guareí e se dedicavam a tal atividade criminosa, o que torna inadmissível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei Antitóxicos, já que os requisitos subjetivos são cumulativos, de modo que a falta de qualquer deles, inviável o reconhecimento da causa de diminuição.

Observo, no tocante ao regime prisional, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, afastando a obrigatória imposição de regime de pena inicial fechado a crimes hediondos e assemelhados, tal como na hipótese destes autos, que versam sobre tráfico ilícito de entorpecentes.

Na fixação do regime prisional ao condenado pela prática do crime de tráfico de drogas deverão ser observados os requisitos dos artigos 33 e 59 do Código Penal,

conjugados ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, atento às circunstâncias da infração penal, aferidas durante a instrução processual, que indicam que, os réus foram surpreendidos em momento em que transportavam 07 (sete) pedras e 01 (uma) porção grande de "crack", e 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, quantidade expressiva, com capacidade de destruição de várias pessoas, drogas com alto poder de destruição do consumidor, Considerando ainda a circunstância que permite aferir terem os réus colaborado dolosamente para a difusão da substâncias entorpecentes, sobretudo nas ruas de bairro conhecido como área de venda de drogas onde há livre circulação de pessoas, Além das consequências reais da infração, já que o tráfico ilícito de entorpecentes invariavelmente causa intranquilidade no meio social, por destruir o núcleo familiar dos viciados, pela ínfima quantia de dez reais, além de aumentar os índices de criminalidade, porquanto os usuários não raras vezes cometem crimes contra o patrimônio com ou sem violência contra a pessoa para obter recursos e assim manter o vício, bem como as despesas do poder público com segurança pública e saúde pública, advindas das internações, cada vez mais frequentes, de novos narcodependentes, levados a esse estado de dependência por pessoas sem escrúpulos como os réus; A prova produzida deixou bem nítido que os réus eram comerciantes de drogas, e que têm personalidade marcadamente deformada; mesmo porque, a despeito de passar por necessidades para alimentar os filhos, nada justifica a destruição de outras pessoas e suas famílias para dar sustento aos seus próprios filhos como tenta se justificar Jussara; Assim evidencia-se que o condenável procedimento dos réus evidencia intensa culpabilidade, uma periculosidade latente, evidenciada pelo desprezo pela vida do próximo, indiferença pela destruição da família do viciado, uma conduta social devastadora, Assim, avaliado o caso concreto, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o regime será inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mesmo que aplicado o disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, avaliado o caso concreto deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por entender que a concessão desse benefício é incompatível para o agente que foi condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, crime equiparado a crime hediondo.

Mesmo porque o artigo 44, inciso III do Código Penal obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito àqueles que por sua personalidade, como os réus, que se dedicam a atividades criminosas, sejam beneficiados com a substituição. No presente caso, os réus almejavam vender ou distribuir cocaína e maconha e o teriam feito sem remorso, se não fosse a intervenção da Polícia Militar; Assim, a despeito da quantidade, a natureza da droga apreendida adquirem relevância quando confrontadas com as circunstâncias da apreensão, que revelam o tráfico danoso à sociedade, que não pode ser equiparado a crime de menor potencial ofensivo, passível de ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Acrescento, por fim, que o montante de pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos de reclusão, obsta a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Acrescento que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos também é vedada pelo artigo 44 da Lei n.º 11.343/2006.

Cumpridos mais de dois terços da pena privativa de liberdade, atendidos os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, e artigos 131 e seguintes da Lei de Execuções Penais, o réu poderá ser beneficiado com o livramento condicional; conforme artigo 44, parágrafo único da Lei n.º 11.343/06.

Quanto ao valor unitário da pena pecuniária, considerando-se a situação financeira dos réus, é fixado no mínimo legal (artigo 43 da Lei Federal n.º 11.343/06).

Diante do todo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva inserida na denúncia para condenar GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO, ADRIAN DIUARE SANTOS PEREIRA CONSOLMAGNO, OLIVER DOMIGUES ALVES ao cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, somente não podendo ser beneficiados com o livramento condicional e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (artigo 43 da Lei Federal n.º 11.343/06) por infração aos artigos 33 e 35, todos da Lei Federal n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Fixo cada dia-multa no seu mínimo legal, estabelecido no artigo 43 da Lei Antitóxicos. Sobre a pena de multa incidirá correção monetária a partir da data do trânsito em julgado desta decisão.

Durante o processamento de eventuais recursos interpostos contra a presente sentença condenatória, os réus deverão permanecer presos. Este Juízo vem adotando o entendimento de que nos delitos de tráfico de entorpecente, o regime prisional deve estar em consonância com o que determina o artigo 2º, § 3º, da Lei Federal n.º 8.072/90, principalmente, como no caso dos autos, onde o a atividade ilícita dos réus, dissemina substâncias nocivas e fomenta a prática de outros crimes, em especial aqueles contra o patrimônio. Aliás esse entendimento já foi prestigiado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no venerando acórdão proferido nos autos do HABEAS CORPUS n.º 205.806-3/4, da Comarca de São José do Rio Preto, da Colenda Primeira Câmara Criminal, relator eminente Desembargador ANDRADE CAVALCANTI, j. 15/4/96, votação unânime. A jurisprudência prevalecente é nesse sentido (RHC 1.141 da 5ª Turma do STJ, DJU, 10 jun. 1.991, pág. 7857; TJSP, HC 160.747, JTJ 155/328; TJSP, HC 78.729, 6ª Câmara; TJSP, HC 77.699, 4ª Câmara; RJTJSP 118/551, 120/586, 122/546, 126/438; RT 643/298; RTJ 146/619 (STF); e RHC 545, 5ª Turma (STJ), e está cristalizada na Súmula nº 9 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reforçada por decisão do Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em venerando acórdão relatado pelo eminente Ministro NERI DA SILVEIRA, que deixou expresso não assegurar a “Convenção Americana sobre Direitos Humanos” (Pacto de São José da Costa Rica) qualquer imunidade à prisão processual: “Ora, cuida-se, aí, de princípio de nosso vigente sistema constitucional, sendo inclusive, não menos importante, a regra de presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão. Não vejo, pois, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, invocada da tribuna, qualquer acréscimo nas garantias individuais e na proteção ao réu. A prisão do art. 594 do Código de Processo Penal não é inconciliável com a regra do art. 5º, LVII, da Constituição, conforme tem esta Corte proclamado. Não há ver, na Convenção em referência, regra de maior eficácia do que o sistema da Constituição, nem se pode entender que norma internacional faça inserir, em nosso ordenamento, preceito em conflito com a Constituição. Esta, como se acentuou, consagra, também, o duplo grau de jurisdição, tal como na Convenção. Não vejo, a partir daí, por igual, haja a Convenção revogado a norma do artigo 594 do Código de Processo Penal” (Habeas Corpus nº 72366-SP, julgado em 13 de setembro de 1.995).

Em tema de proteção ao status libertatis, referido pacto proclama que “ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas” (artigo 7º, n.º 2). E, como muito bem observou o eminente Ministro CELSO DE MELLO: “na realidade, essa cláusula da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao remeter ao plano do direito positivo interno a definição normativa das hipóteses de supressão da liberdade pessoal, admite que o sistema jurídico nacional ou doméstico de cada Estado institua – como o faz o ordenamento estatal brasileiro – os casos em que se legitimará a privação antecipada do status libertatis do réu ou condenado” (Habeas Corpus n.º 72.610-MG, julgado em 05.12.95, cujo despacho foi publicado no DJU de 1º.02.96, pág. 279).

Vedado, portanto, aos réus o direito de recorrer em liberdade, nos termos do artigo 2º, § 3.º da Lei n.º 8.072/90 porque, os réus foram condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado e a segregação impedirá a continuidade do tráfico por eles desenvolvido em associação.

Transitado em julgado, os réus terão os seus nomes lançados no livro “Rol dos Culpados”.

Decreto a perda dos bens e dos valores apreendidos em favor da União, nos termos dos artigos 63 da Lei n.º 11.343/06 e 91 do Código Penal.

Recomendem-se os réus nas prisões em que eles se encontram, uma vez que não poderão recorrer em liberdade pelas razões retro expostas.

Custas processuais na forma da Lei n.º 11.608/03.

Publique-se; Intimem-se, Comunique-se.

Porangaba, 30 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA